

1500825-96.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200328/2021 - DEL.SEC.BAURU

PLANTÃO, 19228368 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 4118/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO,

2200328 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500825-96.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500825-96.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200328/2021 - DEL.SEC.BAURU

PLANTÃO, 19228368 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 4118/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO,

2200328 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAYCON WILLIAM DE SOUZA BIAZI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

1) MAYCON WILLIAM DE SOUZA BIAZI e PAMELLA BOTIN MARINO foram dados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 25 de julho de 2021, por volta das 20h20, na rua Jorge Schneyder Filho, quadra 01, esquina com a rua Natal Fornazari, Jardim Country Club, agindo em concurso, traziam consigo, para fins de tráfico, 235 gramas de cocaína, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. 2) MAYCON WILLIAM DE SOUZA BIAZI também foi dado como incurso nas penas do art. 330 do

Código Penal, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, desobedeceu ordem legal de funcionário público..

Notificados (fls. 174 e 176), os réus apresentaram a defesa preliminar de fls. 177/181.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 06 de outubro de 2.021 (fls. 227/230).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 256 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 260/270).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 275/278, alegando que: 1)- o acusado não tem antecedentes criminais e tem residência fixa; 2)- ele não pratica tráfico; 3)- a droga apresentada pela polícia não pertence a nenhum dos réus; 4)- não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados ao preparo, embalagem e pesagem de droga, a não ser na rua e que não pertence aos réus; 5)- não há prova de que o acusado pretendia vender a droga encontrada em sua residência. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão de fls. 18 e pelo laudo pericial de fls. 123/126 (oitocentos e trinta e cinco porções de cocaína com peso de 253 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos aos acusados.

Interrogada na polícia, a ré Pamela declarou que Maycon não parou o carro mesmo em face da ordem dos policiais e, num dado momento, pegou uma sacola atrás do banco e a arremessou pela janela de seu lado. Na sacola, havia cocaína. Outras viaturas fecharam a rua e seu companheiro parou o veículo. Ele contou para os policiais ter dispensado a droga. Faz alguns dias que Maycon pega entorpecente e o guarda no apartamento, levando-o depois para uma biqueira no bairro Ferradura Mirim. A quantidade de droga existente na sacola era grande. O material ficava guardado em sua casa sob uma mesa da cozinha. Durante o dia, Maycon, sozinho, já havia feito uma entrega de entorpecente. Ele recebia quinhentos reais por semana como contrapartida. Sabia da presença da droga dentro do veículo, bem como que a levariam até o ponto de venda (fls. 10).

Interrogado na polícia, o réu Maycon declarou que a droga - cerca de 840 pinos de cocaína - lhe pertencia. Tentou fugir dos policiais, mas logo em seguida parou o carro. Jogou a sacola que continha os pinos de cocaína pela janela do automóvel. Iria levar a droga ao bairro Ferradura Mirim. Resolveu praticar a conduta em questão há um mês. Pamela sabia de sua conduta e do entorpecente. Na data em apreço e numa outra ocasião, ela o acompanhou até o local de entrega. Ganhava quinhentos reais por semana (fls. 12).

Em juízo, a testemunha Luiz Felipe Babine, policial militar, afirmou que realizava patrulhamento pelas imediações da Avenida Cruzeiro do Sul. Em dado momento, um cidadão veio até a viatura e informou que um indivíduo a bordo de um veículo Fiat Stylo, de cor preta, estaria transportando drogas do bairro Otavio Rasi até o bairro Ferradura Mirim. De posse de tal informação, fez contato com outras equipes solicitando apoio para intensificar patrulhamento na região. Quando estava na rua Jorge Schneyder, viu o veículo com as características informadas vindo no contrafluxo. Fez o retorno e deu sinal de parada ao condutor do automóvel. No entanto, ele passou a fugir. Quando o veículo dos acusados acessava a Avenida Cruzeiro do Sul para entrar no bairro Ferradura Mirim, percebeu que a passageira arremessou uma sacola pela janela do passageiro. Parou a viatura e seu companheiro desceu rapidamente para recolher a sacola. Em seguida, voltaram à perseguição ao veículo. O automóvel desceu a Avenida Cruzeiro do Sul e acessou a Rua Oito, já no bairro Ferradura Mirim. Contudo, já havia uma viatura no caminho, à frente, bloqueando-o. O motorista ainda tentou passar pela lateral dessa viatura, mas a

guarnição conseguiu fechar-lhe o acesso. Conseguiu fazer a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi achado. Indagados sobre a sacola, os réus disseram que, no interior dela, havia eppendorfs de cocaína. Um outro policial chegou com a sacola, tendo sido possível constatar que, nela, havia 835 pinos de cocaína. Os acusados afirmaram que tinham por função guardar droga na casa deles e abastecer o ponto de tráfico. Eles explicaram ser a terceira vez que faziam o abastecimento, bem como que, na residência, nada mais havia, pois era a última vez do dia que levavam o material ao ponto. Ainda segundo os acusados, eles fizeram um abastecimento pela manhã, outra à tarde e iriam fazer a terceira naquele momento, à noite. Os policiais tiveram dificuldade de abordar o veículo ante a fuga e em abordar o réu Maycon. A sacola foi arremessada pela ré Pamela, esposa de Maycon, pela janela do passageiro, cujo assento ela ocupava. Pamela admitiu ter sido ela quem arremessou a sacola. Os réus admitiram que ganhavam dinheiro para exercer a tarefa. Para os policiais, ficou claro que Pamela tinha conhecimento do que fazia, porque os dois foram separados e disseram coisas identificadas, inclusive que a droga ficava escondida sob a mesa da cozinha da casa. Devido ao farol da viatura, foi possível enxergar dentro do veículo perseguido e notar que a sacola foi atirada pela passageira. Os policiais não foram na residência dos acusados. Eles afirmaram que faziam as entregas diariamente. Não se lembra se os réus disseram há quanto tempo realizavam tal atividade. Os réus fugiram por uma quadra inteira da rua Jorge Schneyder e, depois que fizeram curva, arremessaram a droga, desceram uma quadra curta da Avenida Cruzeiro do Sul e já quebraram a primeira à direita na rua Oito, tendo sido abordados na sequência.

A testemunha Bruno de Almeida Krugner, também policial militar, disse que estava em patrulhamento e recebeu informação de populares de que um veículo Stlyo, de cor preta, estaria trazendo drogas ao bairro. Os policiais passaram a patrulhar para encontrar o carro em questão. Na rua Jorge Schneyder, avistou o veículo e deu ordem de parada. O condutor não obedeceu a ordem. Os policiais passaram a fazer o acompanhamento. No cruzamento com a Avenida Cruzeiro do Sul, a pessoa que estava no banco do passageiro do automóvel dispensou uma sacola plástica na esquina. Um policial desembarcou e recolheu a sacola, voltando ao acompanhamento. Na rua Oito, no bairro Ferradura Mirim, uma outra viatura policial conseguiu fechar a frente do automóvel. Foi então possível a abordagem aos ocupantes do veículo. Na busca pessoal, nada foi encontrado. Na sacola dispensada, havia cocaína. Indagados, os réus disseram que recebiam droga e um dinheiro para abastecer a biqueira da rua Oito. Eles também contaram que, na data em questão, era a terceira vez que faziam o abastecimento. Ainda segundo os acusados, eles exerciam tal função há algum tempo. Não teve contato com os réus em datas anteriores. Eles afirmaram abastecer o ponto com aquela quantidade, mesmo em ocasiões anteriores. Pamela admitiu ter envolvimento com o fato, bem como que, naquele dia, era a terceira viagem que faziam. Ela ainda contou que, na residência do casal, a droga ficava armazenada debaixo de uma mesa na cozinha do apartamento mas que, naquele momento, nada mais havia. Era ela quem estava no banco do passageiro. Pamela também confessou ter atirado a sacola para fora do carro.

Interrogado em juízo, o réu Maycon declarou que vinha pela rua Jorge Schneyder e viu a viatura. Como seu carro estava com os documentos vencidos, ficou com medo quando escutou a sirene. Continuou seguindo, mas não acelerou. A avenida é curta. Virou para entrar no bairro Ferradura Mirim e parou o carro, pois temia que acontecesse algo, haja vista que sua esposa estava grávida. Não jogou droga. Não tinham entorpecente. Ia para um pagode com sua esposa, na Faculdade da UNIP. Iriam comprar bebida numa adega e, depois, seguir para o pagode. Sua esposa estava grávida de seis meses. Explicou aos policiais que fugiu porque o documento do carro estava vencido. Nunca teve passagem e nunca foi abordado. Não tem problemas com a Justiça.

Interrogada em juízo, a ré Pamela declarou que não estavam "com nada". Seu marido não parou o veículo com medo de perder o documento do carro. Estava muito nervosa. Desceu do carro nervosa e os policiais fizeram muitas perguntas. Eles os separaram e, depois, conduziram-nos para a delegacia, cada qual numa viatura. Logo depois, sua mãe chegou. Não se lembra de muita coisa. Passou mal, porque estava grávida e

com medo. Maycon não apresentou documento do carro para os policiais. Estavam indo para um pagode, que iria ocorrer no "Bravus", perto da Faculdade UNIP. Estava grávida de seis meses. Não tinha outro filho. Na época, morava com Maycon, num apartamento situado no bairro Otávio Rasi. Residiam juntos há oito ou nove meses. Estava nervosa e com medo. Por isso, admitiu que havia droga e "jogou" para Maycon. Antes de entrar na sala para dar depoimento na delegacia, ficou com medo porque lhe disseram que seria presa e perderia a guarda da filha. Não estavam com droga. Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação dos acusados nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

1) Crime de tráfico:

Os réus confessaram a prática do crime em solo policial.

Mesmo em relação a Pamela, deve-se considerar que houve confissão, pois, embora ela tenha dito que foi Maycon quem recebeu a droga e foi quem a atirou pela janela quando da iminência da abordagem policial, admitiu que seguia junto com seu companheiro até o ponto de tráfico a ser abastecido e que sabia da presença do material ilícito no carro.

Se Pamela estava no veículo que servia para transportar o entorpecente até o destino, onde seria vendido no varejo, é porque exercia função relevante na empreitada, mormente se se considerar que Maycon, sozinho, poderia desempenhá-la, embora sem a descrição e a segurança advindas da presença de uma coautora do sexo feminino.

A confissão extrajudicial é relevante elemento de convicção.

Nesse sentido:

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil." (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

No caso, a confissão extrajudicial está corroborada pelos elementos de convicção colhidos na fase de instrução.

Isto porque a prática do crime foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, segundo os quais, durante a perseguição, foi possível notar que Pamela, ocupante do assento do passageiro, dispensou a sacola em cujo interior havia os pinos de cocaína, pela janela respectiva, bem como que Maycon, que dirigia o automóvel, tentou fugir ante à ordem de parada.

Não há razão para colocar em dúvida a palavra dos policiais.

Afinal, por qual razão dois servidores públicos viriam em juízo, na presença do magistrado, para afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoas que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente pela falsa acusação e também de serem demitidos de seus cargos públicos ?

De resto, as afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

A jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello). Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada. Prosseguindo, a negativa dos acusados não condiz com a realidade. Alegaram eles que saíram de sua casa para irem a um pagode nas proximidades da faculdade UNIP. Contudo, como é possível constatar da imagem abaixo, o local da abordagem (figura 1) não faz parte do caminho entre as ruas Miguel Melhado Campos (residência dos réus) e a faculdade UNIP, tratando-se, inclusive, de desvio de caminho completamente desprovido de sentido (figura 2).

Além disso, a trajetória por eles apontada também é caminho mais longo e demorado (figuras 3 e 4), sendo certo que, em regra, motoristas racionalmente escolhem caminho mais curto e rápido, de modo que não havia razão para que os acusados percorressem o caminho que faziam. Embora eles tenham dito que passariam numa adega para pegar bebidas, não explicaram onde o estabelecimento se situava e nem por que não poderiam buscar bebidas em outros locais situado no trajeto normal, sabido que, em Bauru, existem vários estabelecimentos da espécie.

Destarte, não há dúvida de que os acusados transportavam entorpecente no veículo. Da mesma forma, a prova aponta que eles realizavam o tráfico. Com efeito, Maycon e Pamela estavam na posse de nada menos do que 835 eppendorfs de cocaína (235 gramas), embalagem geralmente utilizada para comercialização de tal espécie de entorpecente no varejo, em plena via pública, deslocando-se de um local para outro a bordo de um automóvel. De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato. Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado. Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo ou transporte (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução). Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. Impõe-se, pois, a condenação dos réus nas penas do artigo 33 da Lei Antidrogas.

2) Crime de desobediência:

Como já sustentado, não há razão para colocar em dúvida a palavra dos policiais, o mesmo valendo para a narrativa de que, mesmo diante de sinais determinando a parada, o acusado não obedeceu e seguiu em fuga.

No mais, cabe ressaltar que o próprio réu confessou que ouviu a sirene policial ordenando a parada e ainda assim não obedeceu a determinação do agente público competente.

Por fim, saliente-se que o fato de haver previsão, no Código de Trânsito Brasileiro, de infração administrativa para a conduta daquele que descumpre ordem emanada de agente de trânsito, não se presta para, no caso, para descaracterizar o crime de desobediência.

Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA POR PARTE DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA

PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1- A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 2. No presente caso, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp 1954136 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2021/0265293-7, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 14/06/2022).

Portanto, Maycon deve também ser condenado pelo crime de desobediência.

Passa-se à aplicação da pena, iniciando-se pelo delito de tráfico.

Os réus não ostentam antecedentes criminais (fls. 64/65 e 67).

No entanto, deve-se considerar que eles transportavam nada menos do que 235 gramas de cocaína, subdivididos em 835 porções, quantidade que é considerável, mormente se se levar em conta a espécie de droga de que se cuida.

A par de se tratar de elevada quantidade, a cocaína é entorpecente cuja natureza é especialmente prejudicial aos usuários e à sociedade como um todo.

Como se sabe, o consumo de cocaína, mesmo em quantidade não muito elevada, pode levar o usuário a óbito, sem contar outros males à sua higidez mental.

No tocante à sociedade, deve-se dizer que ela assiste à disparada dos índices de criminalidade contra o patrimônio, inclusive violenta, praticada por agentes que querem obter recursos para adquirir o entorpecente e/ou por agentes que estão sob efeito dele.

Destarte, com base no artigo 42 da Lei n. 11343/2006, eleva-se a pena base em um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

No entanto, os réus confessaram a prática do tráfico em solo policial, o que foi levado em conta para que fossem condenados.

Presente, então, a atenuante da confissão, reconduz-se a pena ao patamar mínimo, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável ao caso a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade e ausência de antecedentes, não se comprovou serem os acusados pessoas dedicadas a atividades criminosas ou integrantes de organização criminosa.

Acrescente-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida.

Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena.

Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado.

Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 - A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de

'atividade criminosa'. 2 - Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se

afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 - Recurso provido, para reduzir a pena

em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. 1.085.039/MG, rel. Min. Maria

Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-

62.2013.8.26.0071).

Aliás, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim decidiu o eminente Ministro:

"Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito, essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Da leitura da decisão transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. O Tribunal de origem destacou que a paciente 'se dedicava à atividade ilícita de modo habitual e reiterado, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e que das circunstâncias em que foi surpreendida pelos policiais militares, isto é, por volta de 1h25 (...) tudo a indicar que não era principiante e fazia do comércio ilícito seu meio de vida, emergindo inegável, portanto, o seu envolvimento com atividade criminosas, notadamente com traficantes de maior porte, seus fornecedores ou patrões." Contudo, não há nos autos nenhum elemento probatório apto a provar a afirmativa de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, especialmente quando se observa que o Parquet somente arrolou como testemunhas os policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ora, a configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos e não de meras ilações, sem correspondência fática. O envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, como apontou a decisão atacada, pressupõe que o agente, no mínimo, pratica ou praticou diversos atos ou, ao menos, está inserido em grupo/organização direcionada ao crime. Entretanto, o ônus de provar tais elementos que afastam a redutora é da acusação, não cabendo ao magistrado colher elementos extraprocessuais para imputar uma reprimenda mais severa, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, o caso trata de condenação pelo tráfico de 7,67 (sete gramas e sessenta e sete decigramas) de maconha, mais 4,5 (quatro gramas e cinquenta decigramas) de cocaína, ou seja, não se trata de quantia vultosa como afirmado no acórdão proferido pelo TJSP. Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tem o paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de traficante primária e não há nenhuma indicação de maior envolvimento em atividades ilícitas." (Habeas Corpus n. 137458/SP, j. 29/09/2016).

Há, é certo, elementos que poderiam conduzir à crença de que, ao menos Maycon estaria a praticar a traficância mediante guarda de droga e abastecimento de um ponto de vendas há cerca de um mês.

Porém, tais elementos são insuficientes para firmar convicção a respeito, pois consistem apenas na confissão extrajudicial e na confissão informal aos policiais militares.

Como se sabe, quando isolados, eles não se prestam à condenação.

Quanto à confissão extrajudicial:

"Sentença absolutória. Apelo ministerial. Condenação por tráfico. Impossibilidade. Confissão em solo policial que restou isolada nos autos. Ausência de outros elementos a corroborar a confissão extrajudicial. Admissão apenas da posse para uso próprio. Condenação pelo art. 28. Possibilidade. Fixada a pena de advertência. Detração anômala. Ocorrência. Apelo ministerial parcialmente provido e julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento." (TJSP, Apelação n. 0001175-05.2010.8.26.0220, rel. Souza Nucci, j. 16/12/2013).

No tocante à confissão informal, socorre-se, uma vez mais, de precedente jurisprudencial:

"Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Confissão informal de Adriana, mencionadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, que não foi confirmada pelas demais provas. Impossibilidade de condenação exclusivamente com base em elementos de provas colhidos na fase inquisitiva. Art. 155 do CPP.

Absolvição mantida." (TJSP, Apelação n. 0000500-40.2017.8.26.0594, rel. Reinaldo Cintra, j. 20 de junho de 2.018).

Do corpo do acórdão, destaca-se:

"Quanto a Adriana, em que pese os policiais responsáveis por seu flagrante tenham dito que ela assumiu a traficância informalmente, fato é que tanto na fase policial como em juízo Adriana negou envolvimento com o tráfico, e o corréu Maykon a isentou de responsabilidade, sendo certo que, conforme bem salientado na r. sentença, a confissão informal, sequer confirmada na delegacia, restou isolada nos autos."

No caso, nada há, além das confissões extrajudicial e informal a demonstrar que, de fato, os réus ou um deles exercia a traficância, abastecendo ponto de tráfico, há período de tempo razoável e de forma reiterada.

Noutro aspecto, mesmo o fato de a apreensão ter recaído sobre 235 gramas de cocaína permite concluir que se trata de agentes dedicados a atividade criminosa.

É que, segundo entendimento dos Tribunais Superiores (STJ e STF), a mera alusão à quantidade de entorpecente, dissociada de qualquer outra circunstância, não é hábil a impor tal conclusão.

Cabível, pois, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Considerando que a quantidade e a natureza da droga já foram levadas em conta na primeira fase de aplicação da pena, não podem mais sê-lo na terceira, haja vista que, segundo o entendimento daqueles mesmos Tribunais Superiores, tal importaria em "bis in idem".

Logo, a redução da pena deve se dar no patamar máximo de dois terços, resultando em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas para o crime do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Conforme já fundamentado, a quantidade e a natureza da droga apreendida importam na maior reprovabilidade da conduta, tanto que ensejaram o aumento da pena base.

Sendo assim, o regime inicial de cumprimento da pena para o crime de tráfico será o fechado, bem como é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Quanto ao crime de desobediência, não ostentando o réu antecedentes criminais, fixam-se as penas no mínimo legal, ou seja, quinze dias de detenção e dez dias-multa, as quais, não havendo modificadoras, são as definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Não é possível a aplicação do concurso material de crimes quanto ao réu Maycon, tendo em vista tratar-se de delitos punidos com penas de espécies diversas (detenção e reclusão).

Isto porque, na forma do artigo 76 do Código Penal, "no concurso de crimes, executar-se-á primeiramente a pena mais grave".

Outrossim, segundo o artigo 681 do Código de Processo Penal, "se impostas cumulativamente penas privativas de liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último a de prisão simples".

Afasta-se, pois, a regra do concurso material.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para: 1)- condenar os acusados Maycon William Souza Biazi e Pamela Botin Marino como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo; 2)- condenar o réu Maycon William Souza Biazi como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal, a cumprir quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, e a pagar dez dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo.

Oportunamente, anatem-se as condenações no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA